Aprovado ou inscrito em concurso público? Conheça seus direitos!

No Brasil, a Constituição Federal, dispõe que a contratação de pessoal, a fim de compor os quadros de servidores no âmbito da administração pública, independente da esfera que se tenha necessidade, deve adotar como regra a contratação mediante concurso público. Neste contexto, inclusive, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento como inconstitucional qualquer forma de ingresso no serviço público sem a prévia realização de concurso público.

De modo a exaurir qualquer ranhura ao certame público, o ente municipal deverá respeitar os princípios basilares que regem qualquer ato praticado pela administração pública, conforme previsão expressa no caput do artigo 37 da Constituição Federal, que faz parte do capítulo que trata da Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Entretanto, há exceções ao princípio do concurso público, quais sejam: (i) nomeação para cargos em comissão, previsto no próprio artigo 37, inciso II da Constituição Federal; (ii) contratação por tempo determinado, a fim de atender necessidade temporária, de excepcional interesse público, a ser estabelecida por lei do ente federado, conforme previsão legal do inciso IX, daquele dispositivo.

Convém esclarecer que a contratação temporária por excepcional interesse público, em nada se confunde com o contrato temporário da iniciativa privada, que é regulado pela Lei Federal e na própria Consolidação das Leis Trabalhistas, tendo como finalidade atender necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou em casos de aumento extraordinário de serviços. Tampouco, com a terceirização de mão de obra, pois esta pode ser utilizada de forma permanente, para atendimento de atividades não finalísticas, tanto no âmbito privado quanto na administração pública.

Feita essa distinção nos institutos quanto à necessidade ser em caráter temporário e o interesse excepcional, no que reza à contratação por tempo determinado pela administração pública, passe-se a análise do processo de seleção em caráter temporário e emergencial.

Neste ponto, quanto ao processo de seleção em caráter temporário e emergencial, o legislador constitucional destacou que "a lei estabelecerá", mas qual seria a lei? De início, o ente público deverá criar a lei, que regulará esse tipo de contratação em respeito à Constituição Federal.

Em outras palavras, o processo seletivo não pode prejudicar a admissão permanente, nem interesse público que não seja excepcional, extraordinário ou fora do comum. Para este último quesito (excepcional interesse público), convém registrar que o termo 'excepcional' - legitima a contratação temporária, de modo que toda e qualquer contratação é para atendimento do interesse público.

Fundamentado na discricionariedade do ente público em questão, quando a contratação temporária for para o atendimento de excepcional interesse público, não há que se falar em

preterição de candidato classificado em concurso público que não foi chamado; um atende a necessidade sazonal do Município, o outro a necessidade permanente.

A título exemplificativo, tem-se a contratação de guarda vidas temporários para atender as cidades praianas em épocas de temporada. O interesse público é excepcional com temporalidade fixada anualmente, pois não seria razoável a contratação mediante concurso público para composição permanente no quadro de pessoal de servidores que somente atuariam em determinados meses do ano.

O Supremo Tribunal Federal, em sentido similar, tem fixado condições para contratação temporária: (i) previsão legal dos casos; (ii) tempo determinado; (iii) necessidade temporária de interesse público e (iv) interesse público excepcional.

Por sua vez, no Estado de Santa Catarina, há previsão expressa na Constituição Estadual (artigo 21, §2º) acerca do assunto, em perfeita simetria ao disposto pela Constituição Federal (artigo 37, IX), devendo ser clara a existência concomitante de três requisitos autorizadores: (i) situação de excepcional interesse público; (ii) temporariedade da necessidade e (iii) hipótese prevista em lei.

Neste sentido, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina já se manifestou em diversos prejulgados acerca da contratação por tempo determinado e admissão em caráter temporário – ACT no serviço público, do qual se cita o Prejulgado n. 1927 do TCE.

Todos esses pontos são importantes para clarificar possíveis questionamentos na seara do direito administrativo que poderão surgir ao leitor quando da realização de Processo Seletivo Simplificado por Municípios, a título de exemplo o Edital n. 001/2019 – PMV, de Videira, que está em curso para contratação em caráter temporário de aproximadamente 56 cargos.

Cargos esses que, ao mesmo tempo, possuem 02 (dois) certames públicos anteriores vigentes: (i) concurso público n. 001/2018, para preenchimento de vagas de caráter efetivo do quadro funcional, cuja homologação final e lista dos aprovados restaram publicizadas por meio do Decreto n. 15.294/2018, de 29 de junho de 2018; ii) concurso público n. 002/2018, para preenchimento de vagas de caráter efetivo do magistério, cuja homologação final e lista dos aprovados restaram também publicizadas por meio do Decreto n. 15.295/2018, de 29 de junho de 2018.

Ressalvada a discricionariedade do ente público para realização do novo certame (Processo Seletivo), ainda que vigentes concursos anteriores (Concurso Público) já realizados, amparado sob lastro da legislação municipal vigente (Lei Complementar n. 118/2011, Lei Complementar n. 122/2012 e Lei Ordinária n. 2369/2010), para proceder à admissão em caráter temporário e formação de cadastro reserva de excepcional interesse público, a fim de evitar qualquer violação à legislação, bem como infração administrativa em prejuízo do erário, podemos consignar que as contratações por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (ACT) precisará respeitar a lei para não incorrer em fraude ao concurso público já realizado e ainda vigente, quanto a possibilidade de chamamento dos candidatos ali aprovados, de maneira a não gerar novos custos com elaboração de novo certame, haja vista a intenção da administração pública no preenchimento de determinada vaga.

A controvérsia diz respeito não apenas à existência ou não de direito subjetivo à nomeação para cargo em razão da aprovação em concurso público, em detrimento de novo certame (Processo Seletivo) dentro da vigência de certame anterior. Mas, como ficam aqueles candidatos aprovados nos certames anteriores (Concurso Público) ao novo (Processo Seletivo Simplificado n. 001/2019 – PMV) lançado pela Prefeitura Municipal de Videira? E, mais a expectativa frustrada dos atuais inscritos que pretendem realizar a prova apesar de existir apenas Cadastro de Reserva.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema n. 784 no Recurso Extraordinário n. 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, em 09.12.2015, entendeu que o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados além do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame extrapola a mera expectativa de direito à nomeação.

A abertura de novo certame público precisará ser acompanhada da demonstração inequívoca da necessidade premente e inadiável de provimento dos cargos, interpretação do artigo 37, inciso IV da Constituição Federal.

Se houver, no entanto, preterição, convolação excepcional da mera expectativa de direito subjetivo à nomeação, em desrespeito aos princípios da eficiência, boa-fé, moralidade, impessoalidade e da proteção da confiança, força normativa do concurso público, em verdadeiro desinteresse da sociedade, desrespeitando à ordem de aprovação, deverá o segundo certame ser tornado sem efeito para tanto.

O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas, este posicionamento encontra perfeita simetria com a legislação, e também com o entendimento de nossa corte superior, conforme julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.

O Estado Democrático de Direito Republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não apenas pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.

Ressalvada a discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas de concurso público da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, a publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a

prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.

No entanto, e já encaminhando as considerações finais, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, respeitadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, a discricionariedade ou seja, a livre escolha da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público ficará reduzida ao patamar zero fazendo surgir o direito subjetivo à nomeação nas seguintes hipóteses excepcionais: (i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (STF – Julgado RE 598.099); (ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); (iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública.

Não há ilegalidade, em princípio, na contratação de pessoal em caráter temporário pela Administração para suprir necessidade temporária de serviço; porém, se essa transitoriedade não se verificar, e se houver concurso público em vigor, com candidatos aprovados aguardando nomeação para cargo com as mesmas atribuições e com a mesma lotação dos temporários, restará caracterizada preterição a ensejar a violação de direito líquido e certo dos concursados, assim é o entendimento judicial concernente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (p. ex.: Mandado de Segurança n. 2013.027452-6, da Capital, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba j. 12.8.2015).

Feitas essas ponderações, cabe apenas deixar ao bom alvitre do leitor a análise quanto ao emprego do dinheiro público pela administração na abertura de novo certame para preenchimento de cargos públicos, haja vista a existência de concurso em andamento, com candidatos aprovados e aguardando serem chamados ao ingresso.

Fica a indagação do real interesse público na contratação, em caráter temporário, pois sequer mencionado no edital do processo seletivo simplificado o número de vagas que urge a necessidade, já que temporária e não longeva, a oportunizar o simples chamamento dos candidatos já aprovados no certame realizado e ainda vigente.

Destaca-se que incumbe ao operador do direito informar sobre o entendimento técnico, a fim de contribuir com o desenvolvimento da sociedade, pois cabe aos jovens aperfeiçoar as instituições, apurar os conceitos e passar aos vindouros uma Pátria maior, mais confiante e melhor dotada.

Mirataira Helena Mascarello Haus

Lucas Flores